

1002104-31.2022.8.26.0404

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Repetição de indébito

Magistrado: JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... poderá optar pela contratação de seguro contra roubo, perda ou extravio, cujo prêmio anual não poderá exceder R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos).§ 2º A instituição financeira não poderá aplicar juros sobre o valor das compras pagas com cartão de crédito quando o beneficiário consignar a liquidação do valor total da fatura em uma única parcela na data de vencimento. § 3º É proibida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

1ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia - SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002104-31.2022.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002104-31.2022.8.26.0404

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Repetição de indébito (Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Requerente:

Vilson Fernandes

Requerido:

Banco BMG S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ

Vistos.

VILSON FERNANDES ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos nos autos qualificados. Alega a parte autora, em apertada síntese, que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R\$ 226,16, relativos aos empréstimos sobre a Reserva de Margem Consignável (nº 13646037), não pactuados com o banco réu. Pede a declaração da inexigibilidade da dívida, a cessação dos descontos, a repetição em dobro do valor e a indenização dos danos morais suportados. Além do instrumento de procuração (fl.38 ), acompanharam a inicial os documentos de fls. 34/42.

Concedidos à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 43/44), seguiu-se o deferimento do pleito liminar (fls. 43/44).

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 54/66), seguida de documentos (fls. 67/275), aduzindo preliminar de prescrição e decadência. No mérito sustentou que a contratação se deu de forma regular. Diz que agiu em exercício regular de um direito e que não há fundamento jurídico para repetição em dobro do montante debitado. Assinala que os danos morais alegados não restaram materializados. Pugna, ao final, pela improcedência.

Houve réplica (fls.164/167).

É o relatório.

Fundamento e DECIDIDO.

A ação comporta julgamento imediato, nos termos do art. 355, I, do NCPC, porquanto suficientemente esclarecidas as questões de fato e de direito, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, notadamente em audiência.

Friso, por oportuno, que "julgar antecipadamente a lide é dever do juiz se presentes as condições para tanto, até porque sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR - 5ª Turma, Ag. 51.774-MG, Rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.02.89).

As prejudiciais de mérito não comportam agasalho.

Em primeiro lugar, tem-se que os descontos são realizados mensalmente do benefício previdenciário do autor, a evidenciar que se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se inicia somente a partir do vencimento da última parcela.

Ademais, em se tratando de discussão de responsabilidade contratual, o prazo para ajuizamento da ação é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e não trienal, como prevê o art. 206, §3º, da mesma lei, consoante jurisprudência recente do C. STJ:

"É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual. É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de responsabilidades contratual e extracontratual. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos. Para fins de prazo prescricional, o termo "reparação civil" deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual." (STJ. 2ª Seção. EREsp 1280825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018 - Info 632)).

"A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo diferenciado." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acórd. Min. Felix Fischer, julgado em 15/05/2019 - Info 649). "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com pedido de repetição de indébito, possuem natureza pessoal e prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp nº 1.632.888/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 19/10/2020).

Como se vê, o termo inicial do prazo prescricional não ocorreu e, de todo modo, o prazo não é o reputado pelo banco réu, motivo pelo qual não há se falar em prescrição.

Também não se reconhece a ocorrência de decadência, pois o autor afirma na inicial que não firmou qualquer contrato, ou seja, o contrato é alegadamente nulo, pois inexistente.

Como cediço, o negócio jurídico nulo é deveras grave, pois ofende a ordem pública e é insuscetível de confirmação ou convalidação (art. 169 do CC), sendo que a nulidade pode ser alegada, a qualquer tempo, por qualquer interessado ou pelo Ministério Público (art. 168 do CC), e ainda ser reconhecida de ofício pelo juiz (art. 168, parágrafo único, do CC).

Já os vícios que geram a anulabilidade do negócio jurídico são menos graves, de modo que são passíveis de confirmação (art. 172 do CC) e podem convalidar (arts. 178 e 179 do CC); devem necessariamente ser invocados pelos interessados (art. 177 do CC) e se sujeitam ao prazo decadencial de 4 anos, salvo disposição diversa da lei. No caso dos autos, como já dito, o requerente não alega que tenha firmado contrato em erro, ou sob outro vício, mas que o referido negócio não existe, pois

não contratou a modalidade de cartão de crédito RMC. Assim, há que se reconhecer que se trata de pretensão não sujeita a prazo decadencial.

Passo à análise do mérito da causa, ação é improcedente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). De acordo com os artigos 2º e 3º do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolva atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Observe-se que a parte ré é instituição financeira fornecedora de serviços, colocados à disposição no mercado consumidor, sendo a relação firmada entre as partes regida pelas normas contidas no diploma legal supracitado. Aliás, o artigo 3º, § 2º, do CDC, é expresso ao impor que, para fins de definição do fornecedor, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

E, tratando-se de relação de consumo e estando presentes os requisitos do art.

6º, VIII, da Lei 8078/90, quais sejam, a verossimilhança das alegações do autor e a sua hipossuficiência, inverte o ônus probatório.

Dessa forma, nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo ele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que causar pela falha na prestação de seus serviços. Nesses termos, é indispensável para fins de configuração da responsabilidade civil que fique comprovada a conduta ilícita praticada pelo fornecedor, o resultado e o nexo de causalidade.

Pois bem.

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (modalidade RMC) é legal, e está amparado no art. 6º, §5º, da Lei n. 10.820/03, com a redação anterior às da Medida Provisória n. 681, de 2015, e da Lei n. 14.131, de 2021), e também, na Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, alterada pela Instrução Normativa nº 37, de 1º de abril de 2009 e 39, de 18 de junho de 2009.

In verbis: “LEI n. 10.820/03 (...) Art. 6º. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 10 e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (...) § 5º. Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios”.

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES. nº 28/2008 (...) Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade; II - a instituição financeira poderá cobrar até R\$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes. Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - o número de pagamentos não poderá exceder sessenta parcelas mensais e sucessivas; II - o limite máximo de comprometimento é de até duas vezes o valor da renda mensal do benefício; III - a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% (três inteiros e meio por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo; IV - é vedada a cobrança da TAC e quaisquer outras taxas administrativas, exceto a prevista no inciso II do art. 15 e § 1º deste artigo; e V -

o beneficiário, ao constituir a RMC, não poderá ser onerado com a cobrança de qualquer custo adicional de manutenção ou anuidade, excetuando o previsto nesta Instrução Normativa, de forma que a taxa de juros expresse o custo efetivo do cartão de crédito. § 1º O titular do cartão de crédito poderá optar pela contratação de seguro contra roubo, perda ou extravio, cujo prêmio anual não poderá exceder R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos). § 2º A instituição financeira não poderá aplicar juros sobre o valor das compras pagas com cartão de crédito quando o beneficiário consignar a liquidação do valor total da fatura em uma única parcela na data de vencimento. § 3º É proibida a utilização do cartão de crédito para saque. (Alterado pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 37, de 1º de abril de 2009 - DOU de 02/04/2009) Art. 17. A instituição financeira deverá encaminhar aos titulares dos benefícios com quem tenha celebrado contrato de cartão de crédito, mensalmente, extrato com descrição detalhada das operações realizadas, onde conste o valor de cada operação e local onde foram efetivadas, bem como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas."

Como se vê, é possível a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável desde que exista solicitação formal do beneficiário nesse sentido; ou seja, deve haver evidente manifestação de vontade das partes em celebrarem um contrato para fornecimento e uso desse tipo de cartão de crédito.

No caso dos autos, o banco réu apresentou o contrato assinado datado de 18/05/2015, acompanhado dos documentos pessoais do autor (fls. 69/71), documentos esses que foram impugnados pelo autor em réplica.

Conquanto não haja prova irrefutável de que o autor solicitou e assinou o contrato em questão, não se pode ignorar que, após ter recebido o cartão, o consumidor efetivamente o utilizou, realizando compras e saques: os demonstrativos de saque e os respectivos contratos comprovam que o autor foi o destinatário de saques/créditos nos valores de R\$ 2.000,00 (em 16/11/2015, fls. 58), R\$ 2.365,99 (em 28/04/2016, fls. 58), R\$ 1.192,99 (em 06/04/2020, fls. 59), entre outros saques, bem como que, nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017 (fls. 60), efetivamente utilizou o cartão para fazer compras em estabelecimentos dessa localidade.

Como se vê, ainda que se pudesse pensar que o autor não quis o cartão, restou suficientemente demonstrado que foram creditados valores em sua conta, os quais não foram devolvidos, já que nada há nos autos nesse sentido; e que se utilizou do plástico para realizar compras, sendo bastante óbvio que, qualquer que seja a modalidade do uso do cartão de crédito existe a obrigação do consumidor em pagar a fatura do que gastou.

Ou seja, passados mais de 8 anos desde que os descontos na conta do autor começaram o primeiro saque ocorreu em novembro de 2015, conforme fls. 58, ele não só não se insurgiu antes, como também, por várias vezes, realizou outros saques e efetivamente utilizou o cartão enviado em seu nome tempos depois, demonstrando, por meio do seu comportamento, que a relação de direito material, de fato, existiu. Inviável que se reconheça, diante de todo o conjunto probatório produzidos nos autos, que o requerente não solicitou o crédito e o cartão, ou ainda, que o banco creditou em sua conta valores de forma forçada, o que somente foi percebido quase depois de uma década pelo aposentado.

Em casos semelhantes, assim já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. pedido de restituição de indébito em dobro e danos morais. Autor que nega ter firmado contrato de cartão de crédito RMC como réu. Provas apresentadas nos autos que revelam que o autor além de realizar empréstimos utilizou o cartão de crédito para compras por longo período. Dívida regular cujo pagamento pelo autor não restou por ele comprovado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1002982-98.2021.8.26.0562; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2022; Data de Registro: 05/10/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Apelante que

alega que pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. Informações sobre o tipo de contrato que estavam claras no instrumento assinado pela apelante. Apelante que utilizou o cartão, conforme faturas apresentadas. Contratação regular. Contrato mantido. Pretensão de conversão da avença em empréstimo consignado que é descabida. Dano moral inexistente. Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível 1000282-62.2021.8.26.0397; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

"Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c.c. restituição de valores e indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão não trazido aos autos. Contudo, não há demonstração de vício de consentimento, porque a autora se beneficiou da operação e utilizou o cartão para a realização de saques complementares e pagamentos, restando incontroversos os créditos em sua conta bancária, na qual auferiu benefício previdenciário. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e exigível. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1012007-62.2021.8.26.0554 Relator (a): Elói Estevão Trolly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

Destarte, considerando que a prova nos autos se formou no sentido de que o contrato de RMC existiu, é válido e eficaz, inexistindo falha na prestação de serviços pelo banco réu ou conduta ilícita, e, conseqüentemente, não há que se falar em dano indenizável.

Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios ao patrono da parte adversa que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Essas verbas serão oportunamente exigíveis, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de estilo.

Publique-se e intimem-se.

Orlândia, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA